

기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 판례 법리

강 선 희*

목 차

- I. 들어가는 글
- II. 기간제근로자의 고용종료와 해고제한법리의 적용
- III. 부당해고 등의 구제신청과 원직복직 등이 불가능한
경우의 구제이익
- IV. 사실상 무기계약 법리의 등장과 한계
- V. 계속 고용 기대권 법리의 전개와 판단구도
- VI. 맺는 글

I. 들어가는 글

1996년의 대법원 전원합의체 판결¹⁾ 및 1997년 말 외환위기 여파로 비
정규직 근로자 수가 급증하여 2006년 기준 임금근로자의 35.5%에 이르
렀고, 비정규직 근로자의 월평균임금 역시 정규직의 62.8%밖에²⁾ 미치지

투고일 2023. 8. 20, 심사일 2023. 9. 3, 게재확정일 2023. 9. 8.

* 고려대학교 일반·노동대학원 강사, 법학박사.

1) 대법원 1996. 8. 29. 선고 95다5783 전원합의체 판결(이하 ‘1996년 전원합
의체 판결’이라 함). 이 판결로 “근로계약은 기간의 정함이 없는 것과 일정
한 사업완료에 필요한 기간을 정한 것을 제외하고는 그 기간은 1년을 초과
하지 못한다.”라고 규정한 구 근로기준법 제23조는 사실상 그 효력을 잃었
고, 1년 이상의 근로계약도 무효라고 할 수 없게 되었다.

2) 통계청, 『경제활동인구조사 근로형태별 부가조사』, 2006. 8. 기준.

못하고 있어 그 격차가 구조화되는 양상을 보여 주었다. 이는 사회양극화의 핵심 문제로 제기되었는데, 입법자는 이러한 문제에 대처하기 위해 비정규직법의 제·개정[기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 ‘기간제법’이라 한다)은 법률 제8074호로 2006. 12. 21. 제정, 파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 ‘파견법’이라 한다)은 법률 제8076호로 2006. 12. 21. 개정]을 통해 사용기간 제한으로 기간제의 남용억제, 그리고 차별금지로 근로조건을 개선하고자 하였다.³⁾ 한편 법원은 위 1996년 전원합의체 판결이 비정규직 근로자의 양산에 상당한 영향을 미친 것에 대한 반성적 고려로서 갱신기대권 법리 등 기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위한 일련의 판례 법리를 탄생시켰다. 갱신기대권 등의 판례 법리가 나오거나 기간제법이 제정되기 전에 기간제근로자의 고용종료에 대해 보호할 수 있는 방법이 전무했다고 볼 수 있다.

기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위해 형성된 판례 법리는 크게 외형적인 측면에서 3개의 방향으로 완결성을 갖추었다고 볼 수 있다. 그 첫째는 사실상 무기계약 법리이고, 둘째는 (동일한 사용자를 대상으로) 기간제 근로계약의 갱신기대권과 정규직(무기계약직) 전환 기대권⁴⁾, (새로운 사용자를 대상으로) 고용승계 기대권이며⁵⁾, 셋째는 해고의 효력을

3) 이들 법률의 제·개정 이유(국가법령정보센터)는 ‘기간제근로자, 단시간근로자 등 비정규직 근로자가 급격히 증가하고 이들 근로자에 대한 차별적 처우와 남용행위가 사회적 문제로 대두됨에 따라 기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 사용자의 남용행위를 규제함으로써 이들 근로자의 근로조건을 보호하고 노동시장의 건전한 발전을 도모하려는 것’이다. 비정규직법(기간제법과 파견법을 합하여 지칭함)은 한 축으로 차별적 처우를 금지하고, 다른 한 축으로는 비정규직 남용을 규제하는 데에 목적이 있다.

4) 이에 해당하는 기대권 법리로 ‘정년 후 재고용 기대권 법리’가 있으나 이는 정규직을 대상으로 한 것으로서 이글의 주제에서 다소 벗어나므로 필요한 한도 내에서 언급한다. 이와 관련된 내용은 강선희, “정년 후 재고용 기대권-대상판결①: 대법원 2023. 6. 1. 선고 2018다275925 판결, 대상판결②: 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결-”, 월간 『노동리뷰』 2023년 8월호(통권 제221호), 한국노동연구원, 2023, 112-116쪽 참조.

5) 이외에 새로운 사용자를 대상으로 하는 ‘정규직 전환 채용 기대권 법리’가 있다. 정규직 전환 채용 기대권은 2017. 7. 20. 발표된 정부의 ‘공공부문 비

다투던 중의 기간 만료 등에 대한 노동위원회의 구제이익(재심판정취소 소송에서의 소의 이익)의 인정 등이다. 전자의 2가지 판례 법리는 근로 계약기간 만료나 용역업체의 변경 등으로 인한 고용종료로부터 기간제 근로자의 근로관계를 보호하기 위한 법리이고, 후자의 구제이익과 관련된 판례 법리는 근로계약기간 중 사용자의 부당해고 등 부당한 고용종료로부터 기간제근로자를 보호하기 위한 판례 법리이다.

이와 같은 판례 법리는 기간제근로자의 고용종료에 대해 해고제한법리를 적용함으로써 기간제근로자의 근로관계를 보호하는 것이므로 이를 먼저 살펴본 후 나머지 3가지 판례 법리를 구체적으로 검토한다. 그리고 위에서 언급한 기대권은 본질적으로 근로계약의 갱신 또는 정기적으로 전환이나 고용승계 등으로 근로관계가 계속될 것이라는 기대권이므로 통칭하여 ‘계속 고용에 대한 기대권’이나 ‘기대권’으로 표현한다.⁶⁾ 이 글에서 사실상 무기계약 법리와 계속 고용 기대권 법리에 대한 검토는 판단기준에 따른 자세한 검토보다 판례 법리로 등장하게 된 배경과 그 판단구도를 중심으로 살펴볼 것이다.

정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인’에 따라 아웃소싱업체에 맡겼던 업무를 자회사를 설립하여 자회사에 해당 업무를 위탁하는 경우 종전 아웃소싱업체 소속 근로자에 대해 자회사의 정규직으로 전환하여 채용하는 경우이다. 이는 위 가이드라인에 따라 이루어진 것으로 실무에서의 확장성은 그리 커 보이지 않는다.

- 6) 판례가 표현하는 ‘기대권’은 근로자의 입장에서 파악된 개념으로 보인다. 기간을 정한 근로계약이 형식에 불과하여 사실상 무기계약을 체결한 것과 다름없다거나 일정한 요건을 충족하면 근로계약을 갱신하거나 재고용하는 등 계속 고용하겠다는 약정이나 관행으로 신뢰관계가 형성되어 있다면 근로자로서는 계속 고용될 것이라는 ‘기대’가 형성된다는 것이다. 이를 사용자의 입장으로 표현하면 ‘의무’ 즉 갱신할 의무, 승계할 의무, 재고용할 의무 등이 될 것이다. 이러한 관점에서 파악하면 사실상 무기계약 법리도 ‘기대권 법리’로 포섭할 수 있다.

II. 기간제근로자의 고용종료와 해고제한법리의 적용

1. 법관의 법형성으로서 근로기준법 제23조 제1항 및 제28조의 유추적용

앞서 언급한 판례 법리는 근로계약기간 만료 및 아웃소싱업체의 변경 등을 원인으로 한 근로관계 종료는 원칙적으로 해고는 아니나 계약기간의 만료 등에도 불구하고 근로계약기간을 정한 약정이 형식에 불과하다거나 근로관계가 계속될 것이라는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 이러한 근로관계 종료가 해고와 마찬가지로의 효과가 나타날 경우 예외적으로 근로자의 근로관계를 보호할 목적으로 해고제한법리를 적용하는 것이다.⁷⁾ 해고제한법리를 적용한 결과 부당해고 등을 금지하는 근로기준법 제23조 제1항과 부당해고에 대한 (노동위원회)구제신청을 규정한 근로기준법 제28조가 적용된다.

이와 같은 판례 법리는 법관에 의한 법발견(Rechtsfindung)의 방법이 아니라 법형성(Rechtsfortbildung)의 방법을 통해 법획득(Rechtsgewinnung)을 한 것으로 보인다.⁸⁾ 사법(司法)은 민주적 헌법국가의 권력분립원칙에

7) 대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두16901 판결 등(사실상 무기계약 법리) “이 경우 사용자가 정당한 사유 없이 갱신 계약 체결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효이다.” 이와 같은 취지로 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두 1729 판결 등(갱신기대권 법리), 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결 등[정규직(무기계약직) 전환 기대권 법리], 대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결 등(고용승계 기대권 법리), 대법원 2023. 6. 15. 선고 2021두39034 판결(정규직 전환 채용 기대권 법리), 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결(정년 후 재고용 기대권 법리) 등이 있다.

8) 독일의 전통적인 법학방법론에 따르면 법관의 법획득(Rechtsgewinnung)은 법발견(Rechtsfindung)과 법형성(Rechtsfortbildung)을 통해 이루어지는데, 이는 ‘법문언의 가능한 의미의 한계’를 기준으로 구분하고 있다. 법발견(Rechtsfindung)은 법관의 법률해석이 법문언의 가능한 의미 안에서 실정법에서 해당되는 사안에 관한 법을 찾아내는 것으로 전통적인 해석방법인 문언적, 체계적·논리적, 역사적(연혁적), 목적론적 해석을 통해 도출된 규범의 범위에 사실관계를 포섭시키는 법적용 과정이다. 반면 법관의 법형성(Rechtsfortbildung)은 해당 사안을 규율할 적합한 실정법의 흠결(Gesetzeslücke)로 사안이 법문언의 가능한 의미를 벗어난 경우 위와 같은 전통적인

따라 입법자가 제정한 법률을 구체적 사례에 적용하기만 해야 한다는 법치국가의 상식에서 보면, 법관은 법적용자로서 이미 주어진 척도(규범)를 ‘적용’하는 것에서 벗어나 새로운 법(규범)을 창조하는 의미에서의 법‘형성’은 양립할 수 없는 것처럼 보인다. 그러나 규율하려는 생활관계가 시간에 따라 변하고 현대사회의 복잡성의 증가 등으로 법률을 제정할 당시 입법자가 예견하지 못한 새로운 상황이 초래되는 경우(실정법의 흠결, Gesetzeslücke)에는 법관의 법형성이 허용된다.⁹⁾

기간제근로자의 고용종료에 대한 해고제한법리의 적용은 법원이 ‘유추’의 방식을 통한 법형성이라 할 수 있다.¹⁰⁾ 일반적으로 유추적용(Analogie)은 모든 점에서 같지 않은 유사한 사안, 즉 부분적으로는 서로 일치하나 부분적으로는 서로 다른 사안이 해당 법문언의 가능한 의미에 포섭(Subsumtion)되거나 해석(Auslegung)될 수 없는 경우이더라도 동일하게 취급하는 것을 말한다. 즉 유추적용의 결과 유사한 것으로 인식된 두 개의 사안에 대해 동일한 법적 효과가 부여되므로¹¹⁾ 이를 정당화하기 위해서는 부분적으로 일치하는 부분, 즉 유사한 부분이 본질적으로 일치해야 한다. 앞서 언급한 유형의 고용종료는 근로자의 의사에 반하여

해석방법으로 적용하기 곤란하여 유추적용 또는 목적론적 축소적용과 같은 추론방식을 통해 법적용의 공백을 메꾸는 것이다. 이와 대한 자세한 내용은 김영환, “법학방법론의 관점에서 본 유추와 목적론적 축소”, 『법철학연구』 제12권 제2호, 2009, 7쪽 이하; “한국에서의 법학방법론의 문제점 - 법발견과 법형성: 확장해석과 유추, 축소해석과 목적론적 축소 간의 관계를 중심으로 -”, 『법철학연구』 제18권 제2호, 한국법철학회, 2015, 137쪽 이하 참조.

- 9) 이러한 측면에서 법관의 법형성이 가장 활발하게 이루어지는 영역 중의 하나가 노동법 영역이다.
- 10) 형사법은 죄형법정주의 원칙에 따라 ‘법문언의 가능한 의미의 한계’를 넘어 비슷한 사안에 유추적용해서는 안된다는 원칙(Analogieverbot)이 있으나, 구 근로기준법 제30조 제1항(현 제23조 제1항)에 대한 벌칙(5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금)을 법률 제8293호로 2007. 1. 26.(2007. 7. 1. 시행) 삭제함으로써 이와 같은 논란으로부터 자유로워졌다.
- 11) 이에 대한 정당화는 같은 종류의 것은 법적으로 동일하게 취급하라는 정의의 요청으로부터 생겨난다고 한다. 즉 ‘같은 것은 같게’라는 원칙에 따라 법적용의 범위를 확대하는 것이다. 칼 라렌츠(김영환 역), “방법론적인 문제로서 법관의 법형성”, 『법학논총』 제25집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2008, 8쪽 참조.

근로관계가 종료되었으나 이것이 사용자의 일방적인 의사표시에 의하여 이루어지는 ‘해고’는 아니면서¹²⁾ 근로관계가 계속될 것이라는 신뢰관계가 형성되어 있는 근로자에게는 해고와 같은 결과가 나타나는 경우이다. 여기서 ‘해고’의 본질은 근로자가 계속 근로에 대한 신뢰이익을 가질 만한 정당한 근거가 있음에도 이에 반하여 사용자에게 의해 갱신 거절 등으로 근로관계가 강제 종료된 것이므로 ‘결과’ 내지 ‘효과’라는 측면에서 위와 같은 고용종료는 해고와 본질적으로 같다고 할 수 있다. 다만 이와 같은 고용종료에는 근로관계를 종료하고자 하는 사용자의 ‘명시적 또는 묵시적 의사표시’가¹³⁾ 없기 때문에 ‘해고’ 자체는 아닌 것이다. 이러한 점에서 앞서 언급하였듯이 기간제근로자의 고용종료에 대해 근로기준법 제23조 제1항과 제28조의 규정을 유추적용하는 것이고, 이것이 해고제한법리의 내용이다. 그러나 이와 같은 고용종료는 ‘해고’ 자체는 아니므로 근로기준법의 해고제한규정들, 즉 근로기준법 제23조 제2항의 해고 금지시기, 제26조의 해고의 예고, 제27조 해고사유 등의 서면통지 등의 규정은 적용되지 않는다(근로기준법 제24조도 마찬가지이다).

2. 해고제한법리의 적용과 관련된 몇 가지 법적 쟁점

필자는 계약기간 만료 내지 정년을 알리는 사용자의 통지가 ‘관념의 통지’라는 대법원 2008. 2. 29. 선고 2007다85997 판결 등은 기간 만료 등의 정당성에 대한 법적 평가 이후에야 주어지는 법적 결과에 불과하므로 이에 한정하여 해석해야 하고 선제적으로 해고제한법리의 적용 여부에서 판단할 문제가 아니라는 견해를 밝힌 적이 있다.¹⁴⁾ 즉 계약기간 만료 등이 정당하면 이를 알리는 사용자의 통지는 ‘관념의 통지’일 것이

12) 해고란 실제 사업장에서 불리는 명칭이나 절차에 관계없이 근로자의 의사에 반하여 사용자의 일방적 의사에 의하여 이루어지는 모든 근로계약관계의 종료를 의미한다(대법원 1993. 10. 26. 선고 92다54210 판결, 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010다92148 판결 등).

13) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022두57695 판결

14) 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 『노동법포럼』 제38호, 노동법이론실무학회, 2023, 159쪽.

고, 정당성이 없는 기간 만료라면 해고와 마찬가지로 해고제한법리를 적용할 것이라는 사고를 바탕으로 한다. 그러나 정당성이 없는 계약기간 만료 등이 ‘해고와 마찬가지로’의 효과가 나타날 뿐 근로기준법 제23조 제1항의 ‘해고’ 자체는 아니므로 ‘관념의 통지’라는 사실을 부인할 수 없다.¹⁵⁾ 다만 기간 만료 등이 관념의 통지라 하더라도 해고제한법리를 유추적용할 수 있으므로, 기간 만료 등이 ‘해고’와 본질적으로 같은지 또는 해고제한법리를 적용할 사안인지를 심리해야 한다.¹⁶⁾ 기간 만료 등을 알리는 사용자의 통지가 ‘관념의 통지’라는 사실로부터 확인할 수 있는 법적 의미는 관념의 통지는 (해고)의사표시가 아니므로 위에 언급한 해고제한규정(근로기준법 제23조 제2항, 제26조, 제27조 등)이 적용되지 않는다는 데에 있을 뿐이다.

한편 위와 같은 기간제근로자의 고용종료에 대해 해고제한법리를 적용한다는 것은 기간 만료 등에도 불구하고 기간제근로자에게 계속 고용에 대한 신뢰관계가 형성되어 있는 경우(사실상 무기계약 법리 및 기대권 등) 사용자가 이를 합리적 이유 없이 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없게 되는 것을 의미한다. 따라서 기간제근로자는 사용자에게 근로관계의 회복과 그와 같은 거절 행위가 없어 계속 근무하였다면 받을 수 있는 임금 상당액을 청구할 수 있다. 즉 기간제근로자는 노동위원회에 부당해고 구제신청을 할 수 있고, 해고무효확인소 내지 근로자지위확인의 소를 제기할 수 있다.

만약 해고제한법리를 적용하지 않고 사법적 청구권의 형태로 적용할 수 있는가? 예컨대 파견법 제6조의2 제1항(“사용사업주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 파견근로자를 직접 고용하여야 한다”)과¹⁷⁾ 같이 사용자가 기간제근로자와 근로계약을 체결할 고용의무를

¹⁵⁾ 위 견해와 배치되는 종전 견해[강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 『노동법포럼』 제38호, 노동법이론실무학회, 2023, 159쪽; “해고의 서면 통지 요건과 갱신 거절 등-대법원 2021. 10. 28 선고 2021두45114 판결-”, 월간 『노동리뷰』 2022년 1월호(통권 제202호), 한국노동연구원, 2022, 133-137쪽]를 수정한다.

¹⁶⁾ 기간 만료나 정년 등이 관념의 통지라는 사실로부터 해고제한법리의 적용을 피할 수 없음을 유념해야 한다.

부담하는 것으로 볼 수 있는지 여부이다. 이러한 고용의무는 고용된 것으로 간주되는 것이 아니라 사용자가 근로자에 대해 고용하겠다는 의사 표시(근로계약을 체결)를 하여야 효과가 발생하는 것이다. 이러한 경우 근로자는 사용자를 상대로 고용 의사표시를 갈음하는 판결을 구할 사법상의 권리가 있고, 판결이 확정되면 비로소 사용자와 근로자 사이에 고용관계가 성립하는 구조이다.¹⁸⁾ 이러한 연유로 근로관계의 존속을 전제하는 ‘해고’제한법리와는 차이가 있다. 정년 후 재고용 기대권과 관련하여 하급심은¹⁹⁾ “(원고의 취업규칙 및 단체협약)…원고가 정년퇴직자에게 일정한 요건이 충족되면 특별한 사정이 없는 한 정년 후 촉탁직 근로관계의 체결을 보장하겠다는 취지의 규정이라고 볼 수는 없으므로, 위 규정들에 의하여 정년이 도래한 근로자들에게 촉탁직 근로계약의 체결을 요구할 수 있는 구체적인 권리가 있다거나 계약 체결에 대한 기대권이 발생한다고 보기도 어렵다.”라고 판시한 내용을 보면 해고제한법리와 청구권 보장 법리에 대해 다소의 혼동이 있었던 것으로 보인다. 이와 관련하여 정년 후 재고용 기대권 법리를 최초로 제시한 대법원 2023. 6. 1. 선고 2018다275925 판결은 사용자가 근로자의 재고용 기대권을 침해한 경우의 법적 효과에 대한 별다른 설시를 하지 않았으나 이로부터 한 달이 되지 않아 나온 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결은 “이와 같이 정년퇴직하게 된 근로자에게 기간제근로자로의 재고용에 대한 기대권이 인정되는 경우, 사용자가 기간제근로자로의 재고용을 합리적 이유 없이 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없다.”라는 내용을 추가로 설시함으로써 이와 같은 경우에도 해고제한법리를 적용한다는 사실을 명확히 하였다.

이와 같이 청구권 보장 법리를 적용할 수 없는 것은 기간제근로자의

17) 구 과건법상 고용의제조항을 2006. 12. 21. 법률 제8076호로 고용의무조항으로 개정된 것이다(2007. 7. 1. 시행).

18) 대법원 2015. 11. 26. 선고 2013다14965 판결, 대법원 2020. 5. 14. 선고 2016다239024, 2016다239031(병합), 2016다239048(병합), 2016다239055(병합), 2016다239062(병합) 판결

19) 서울행정법원 2018. 4. 12. 선고 2017구합76357 판결. 이는 대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결의 1심 판결이다.

고용종료에 대해 본질적으로 성격이 다른 파견법 제6조의2 제1항의 규정을 유추적용할 수 없고, 달리 유추적용할 법규정도 없기 때문이다. 더 나아가 기간 만료 등에도 불구하고 일정한 요건이 충족될 경우 근로계약을 갱신한다거나 재고용한다는 취지의 근로계약, 취업규칙, 단체협약의 명시적인 규정이나 이에 대한 정당한 기대권이 있다면 이에 따라 근로관계는 갱신되거나 재고용된 것이므로 사용자의 구체적인 고용행위(근로계약 체결 행위)를 요하지 않는다.

다른 한편, 일부 하급심은 갱신기대권을 주장하며 부당해고 구제신청을 한 기간제근로자에게 “근로계약이 이미 기간 만료로 종료되었기 때문에 소의 이익이 없어 부적합”하다며 근로자들의 손을 들어준 1심 판결에 대해 각하 판결을 한 사례가 있었다. 이에 대해 대법원은²⁰⁾ “근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없으므로, 근로자로서는 근로계약기간이 만료된 후에도 갱신 거절의 유효 여부를 다룰 법률상 이익을 가진다.”라고 판시함으로써 각하 판결을 한 원심을 파기·환송하였다.²¹⁾ 이는 기간제근로자의 고용종료에 대해 해고제한법리를 적용한 당연한 결과이므로 다시금 논할 필요가 없어 보인다.

20) 부산지방법노동위원회 2013. 10. 14. 판정 2013부해502(근로자들 승) → 중앙노동위원회 2014. 1. 13. 판정 2013부해988(초심 취소_근로자들 패) → 대전지방법원 2015. 3. 25. 선고 2014구합100633 판결(재심판정 취소_근로자들 승) → 대전고등법원 2015. 11. 26. 선고 2015누11279 판결(각하) → 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두59907 판결(파기환송) → (파기환송심) 대전고등법원 2018. 4. 18. 선고 2017누13736 판결(기각_근로자들 승) → 대법원 2018. 7. 13. 자 2018두42474 판결(심리불속행 기각)

21) 이외에도 갱신기대권을 최초로 인정한 대법원 2005. 7. 8. 선고 2002두8640 판결에서도 위와 같은 취지로 판시하였다.

III. 부당해고 등의 구제신청과 원직복직 등이 불가능한 경우의 구제이익

1. 근로계약기간 만료 등과 구제이익(소의 이익)

근로자가 사용자로부터 부당해고 등을 당하여 노동위원회에 구제를 신청하거나 중앙노동위원회의 재심판정에 불복하여 행정소송을 제기하는 경우 구제신청의 이익이 있어야 하거나 재심판정의 취소를 구할 소의 이익이 있어야 한다.²²⁾ 구제이익이란 부당해고 등에 관하여 노동위원회의 공권적 판단(구제명령)을 구하기 위해 가지고 있어야 하는 구체적 이익 내지 필요를 말하고, 소의 이익이란 중앙노동위원회의 재심판정에 불복하여 행정소송을 제기할 경우 재심의 명령이나 처분의 취소를 구할 법률상의 이익을 말한다. 구제신청의 이익이 구체적으로 무엇인지는 근로기준법, 노동위원회법 등에²³⁾ 정한 바가 없다. 한편 노동위원회의 재심판정 취소소송은 행정쟁송으로서의 보편성을 가지므로 행정소송에서의 소의 이익에 관한 일반 법리가 적용되는데, 행정소송법은 제12조에 취소소송은 ‘처분의 취소를 구할 법률상 이익’이 있는 자가 제기할 수 있다고 정하고 있다. 여기서 ‘법률상 이익’이란 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우를 말하며, 간접적이거나 사실적·경제적 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 포함되지 않는다.²⁴⁾

노동위원회가 부당해고라고 판단하면 사용자에게 근로자를 원직에 복직시키라는 명령(원직복직명령)과 더불어 해고기간에 정상적으로 근로

22) 해고무효확인의 소 등과 같은 확인의 소에서 ‘확인’의 이익은 ‘소의 이익’과 다른 개념이므로 여기서는 다루지 않는다. 여기서 말하는 소의 이익은 위에 언급하였듯이 재심판정취소소송에서의 소의 이익을 의미한다.

23) 종전 노동위원회규칙(제60조 제1항 제6호 ‘신청하는 구제의 내용이 법령상이나 사실상 실현할 수 없거나 신청의 이익이 없음이 명백한 경우’)에 따르면 구제이익이 없는 경우 ‘각하’하였으나 2021. 10. 7. 개정 시 이를(밑줄 친 부분) 삭제하였다(2021. 10. 21. 시행).

24) 대법원 2001. 9. 28. 선고 99두8565 판결 등

하였다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 지급하라는 명령(임금 상당액 지급명령)을 하게 된다. 그런데 근로자가 부당해고 구제신청을 하여 해고의 효력을 다투던 중 기간 만료나 정년 등의 사정으로 근로관계가 종료되는 경우 근로자가 더 이상 원직에 복직하는 것이 불가능하게 되기 때문에 노동위원회는 원직복직명령을 내릴 수 없거나 재심이나 행정소송에서 원직복직명령을 유지할 필요가 없게 되는 경우가 발생한다. 이러한 경우 원직복직명령이나 재심판정을 취소하더라도 근로관계의 회복이 불가능하므로 원직복직의 구제명령을 구할 이익 및 재심판정의 취소를 구할 이익이 없게 된다. 이와 같은 위법한 재심판정의 취소를 구하는 소는 그 재심판정에 의해 발생한 위법상태를 배제하여 원상으로 회복시키고, 그 재심판정으로 침해되거나 방해받은 법률상 이익을 보호·구제하고자 하는 소송이기 때문이다.²⁵⁾ 그러나 여기서 근로관계가 적법하게 종료되어 원직복직명령을 구하거나 유지할 수는 없어도 부당해고기간에 받지 못한 임금 상당액을 구할 독자적 구제이익이 있는지를 두고 그간 논란이 되었으나 2020. 2. 20. 선고된 대법원 전원합의체 판결(2019두52386)에 따라 이러한 논란은 일단락되었다.²⁶⁾

종전 판례는²⁷⁾ “근로자가 부당해고 구제신청을 하여 해고의 효력을 다투던 중 근로계약기간의 만료로 근로관계가 종료하였다면 근로자로서는 해고기간 중의 지급받지 못한 임금을 지급받기 위한 필요가 있다고 하더라도 이는 임금청구소송 등 민사소송절차를 통하여 해결될 수 있다.”라는 이유를 들어 소의 이익이 없다며 임금 상당액 지급명령의 독자적 구제이익을 부정하였다. 이러한 가운데 2007년 근로기준법 제30조 제3항의 금품지급명령(금전보상명령)제도의 도입으로 다시금 임금 상당액 지급명령을 구할 독자적 구제이익이 있다는 주장에 힘이 실리면서 노동위원회 및 하급심을 중심으로 부당해고를 당한 때로부터 계약기간 만료 시까지 임금 상당액 지급명령 및 금전보상명령을 하였으나 종전

25) 대법원 1995. 7. 11. 선고 95누4568 판결 등

26) 이하의 일부는 강선희, “부당해고 구제절차와 소의 이익-대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 판결”, 제2판 『노동판례백선』, 한국노동법학회, 박영사, 2021, 206-209쪽의 내용을 참조하였다.

27) 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012두3484 판결 등

판례에 번번이 가로막혀 패소하거나 취소되었다. 이로 인해 기간제근로자가 노동위원회 구제절차를 사실상 이용하지 못하는 불합리한 결과가 발생하고, 사용자가 근로계약기간 중 부당하게 해고하더라도 어떠한 법적 책임을 부담하지 않음으로써 사실상 사용자의 부당해고를 용인해주는 결과를 초래하며, 이러한 사정으로 비정규 고용이 남용될 수 있는 여지를 제공한다는 비판이 있었다. 아울러 원직복직명령이 계약기간 만료 등의 사정변경으로 이행불가능하게 되어 원직복직명령이 실효되더라도 사용자는 임금 상당액의 지급명령을 포함하는 노동위원회의 결정에 따를 공법상의 의무를 부담하므로 사용자로서는 그 의무를 면하기 위하여 재심판정의 취소를 구할 법률상의 이익 및 재심신청의 이익이 언제나 있다고 본 판례의 입장에²⁸⁾ 비추어 보면 근로자와 사용자 사이에 소수수단에 있어 형평에 맞지 않다는 비판도 있다.²⁹⁾

2. 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 판결

2020. 2. 20. 선고된 대법원 전원합의체 판결(이하 ‘2020년 전원합의체 판결’이라 한다)은 “근로자가 부당해고 구제신청을 하여 해고의 효력을 다투던 중 정년에 이르거나 근로계약기간이 만료하는 등의 사유로 원직에 복직하는 것이 불가능하게 된 경우에도 해고기간 중의 임금 상당액을 지급받을 필요가 있다면 임금 상당액 지급의 구제명령을 받을 이익이 유지된다.”라고 판시함으로써 부당해고기간에 대한 임금 상당액 지급명령 및 금전보상명령의 독자적 구제이익을 인정하였다. 이로써 해고제한법리(근로기준법 제23조 제1항 및 제28조)가 실질적으로 작동할 수 있도록 길을 열었다는 점에서 큰 의의가 있다. 2020년 전원합의체 판결이 임금 상당액 지급명령 및 금품지급명령의 독자적 이익을 인정하는 논거를 살펴보면 아래와 같다.

²⁸⁾ 대법원 1993. 4. 27. 선고 92누13196 판결 등

²⁹⁾ 심재진, “근로관계 종료에 따른 부당해고 등 구제신청 구제이익과 재심판정 취소소송 소의 이익”, 『노동법연구』 제32호, 서울대노동법연구회, 2012, 103쪽; 유성재, “임금상당액 지급명령의 독립적 구제이익”, 『법학논문집』 제37집 제3호, 중앙대학교 법학연구원, 2013, 90쪽.

첫째, 부당해고 구제명령제도는 ‘부당한 해고를 당한 근로자에 대한 원상회복, 즉 근로자가 부당해고를 당하지 않았다면 향유할 법적 지위와 이익의 회복을 위해 도입된 제도’이므로 근로자 지위의 회복뿐만 아니라 (원직에 복직하는 것이 불가능하더라도) 해고기간 중의 임금 상당액을 지급받도록 하는 것도 부당해고 구제명령제도의 목적에 포함된다.

둘째, 원직복직명령은 장래의 근로관계에 대한 조치이고, 해고기간 중의 임금 상당액 지급명령은 과거 해고기간 중의 근로관계의 불확실성에 따른 법률관계를 정리하기 위한 것으로 서로 목적과 효과가 다르기 때문에 원직복직이 가능한 근로자에 한정하여 임금 상당액을 지급받도록 할 것은 아니다.

셋째, 노동위원회의 구제명령은 이행강제금(근로기준법 제33조)과 형사처벌(근로기준법 제111조)을 통해 간접적인 강제력을 가지므로 근로자가 해고기간 중의 미지급 임금과 관련하여 강제력 있는 구제명령을 얻을 이익이 있고, 따라서 근로자가 구제명령을 얻기 위해 재심판정의 취소를 구할 이익도 인정된다.

넷째, 해고기간 중의 임금 상당액을 지급받기 위하여 민사소송을 제기할 수 있다는 사정이 소의 이익 내지 구제이익을 부정할 이유가 되지 않는다. 오히려 민사소송과 별개로 신속·간이한 구제절차 및 이에 따른 행정소송을 통해 임금 상당액의 손실을 회복할 수 있도록 한 것이 부당해고 구제명령제도의 취지에 부합한다.

다섯째, 종전 판결은 금품지급명령 제도를 도입한 근로기준법 개정 취지에 맞지 않고, 기간제근로자의 실효적이고 직접적인 권리구제를 사실상 부정하는 결과가 되어 부당하다. 원직복직을 전제로 하지 않는 구제수단을 제도적으로 도입한 점에 비추어 보면 원직복직이 불가능한 경우에도 소의 이익을 인정하여 근로자가 구제받을 수 있는 기회를 주는 것이 타당하다.

3. 근로기준법 제30조 제4항의 입법

1) 한정에 의원 대표발의의 근로기준법 개정안

위와 같은 2020년 전원합의체 판결이 나오자 입법자도 이를 반영한 근로기준법 개정을 추진하였는데, 2020. 6. 29. 한정에 의원(더불어민주당)은 근로기준법 개정안을³⁰⁾ 대표 발의하였다. 그 제안이유는 “노동위원회 부당해고 구제절차는 원직복직이 어려운 근로자를 위한 중요한 권리구제 수단임에도 불구하고, 현행 「근로기준법」은 근로자가 원직복직을 원하지 아니하는 경우에 한하여 원직복직 대신 금전보상을 명하도록 규정하고 있어 노동위원회는 근로계약기간의 종료, 정년, 사업장 폐업 등으로 원직복직이 불가능해진 경우에는 부당해고 여부를 판단하지 않고 각하 결정을 하고 있음. 이에 근로계약기간 종료, 정년, 사업장 폐업 등으로 원직복직이 불가능해진 경우에도 근로자가 노동위원회의 부당해고 구제절차를 통해 금전보상을 받을 수 있도록 하여 제도의 실효성을 제고하고자 함”이라고 밝히고 있다. 주요 내용은 다음과 같다.

“가. 원직복직이 불가능한 경우의 부당해고 금전보상제를 적용함.

- 1) 부당해고된 근로자는 원직복직 또는 금전보상을 신청할 수 있도록 명확한 법적 근거를 마련함(안 제28조제3항 신설).
- 2) 원직복직을 신청한 근로자가 근로계약기간 만료, 정년, 사업장 폐업 등 사유로 원직복직이 불가능한 경우나 원직복직을 원하지 아니한 경우에는 금전보상으로 신청취지를 변경할 수 있도록 규정함(안 제28조제4항 신설).
- 3) 노동위원회가 원직복직을 신청한 근로자가 원직복직이 불가능한 사정이 발생한 사실을 알게 되면 근로자의 신청취지 변경 의사를 확인할 수 있도록 함(안 제29조제4항 신설).
- 4) 노동위원회의 부당해고 구제명령 시, 근로자의 신청취지에 따라 원직복직 또는 금전보상을 명하도록 규정함(안 제30조제3항).”

2) 국회 고용노동법안심사소위의 심사과정과 최종 개정안

2020. 12. 3. 제382회 국회 환경노동소위 제4차 회의에서 위 발의안에 대해 전문위원은 “개정안은 부당해고 구제 신청 시 원직복직과 금전보

30) 한정에 의원 대표발의(한정에 의원 등 17인), 의안번호 제2101145호.

상 중 하나를 선택하여 신청하도록 되어 있어 원직복직을 신청한 근로자의 경우 부당해고 인정될 때에도 원직복직 외에 임금 상당액 지급명령이 제외되는 것으로 해석될 우려가 있으므로 명확히 규정할 필요가 있다고 보입니다.”라는 검토의견을 제시하였다. 이에 대해 고용노동부도 이와 같은 의견을 이미 알고 있기 때문에 위 의견을 수용하여 수정 대안을 제시하도록 하겠다고 밝혔다.³¹⁾ 이에 따라 고용노동부는 해고와 해고 아닌 경우로 구분하여 지급되는 금전보상액의 범위에 대한 수정안을 제시하였고, 2021. 3. 17. 제385회 국회 환경노동소위 제1차 회의에서 해고인 경우에는 원직복직으로, 해고가 아닌 징계 등의 경우에는 원상회복으로 명시하고, 해고인 경우는 해고기간에 받을 수 있었던 임금 상당액, 해고 이외의 경우에는 원상회복에 준하는 금품으로 하는 법률안으로 의견을 모았다.³²⁾ 최종적으로 2021. 5. 18. 법률 제18176호로 근로기준법 제30조 제4항이 신설되었다(2021. 11. 19. 시행).

근로기준법 제30조 제4항: “노동위원회는 근로계약기간의 만료, 정년의 도래 등으로 근로자가 원직복직(해고 이외의 경우는 원상회복을 말한다)이 불가능한 경우에도 제1항에 따른 구제명령이나 기각결정을 하여야 한다. 이 경우 노동위원회는 부당해고등이 성립한다고 판정하면 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액에 해당하는 금품(해고 이외의 경우에는 원상회복에 준하는 금품을 말한다)을 사업주가 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다.”

입법자는 이에 대해 “노동위원회의 부당해고 구제절차는 원직복직이 어려운 근로자를 위한 중요한 권리구제 수단임에도 불구하고 현행법은 근로자가 원직복직을 원하지 아니하는 경우에 한하여 원직복직 대신 금전보상을 명하도록 규정하고 있어 근로계약기간의 종료, 정년 등으로 원

31) 국회회의록, 제382회 국회-환경노동위원회회의록(고용노동법안심사소위원회) 제4호(2020. 12. 3.), 52-53쪽.

32) 국회회의록, 제385회 국회-환경노동위원회회의록(고용노동법안심사소위원회) 제1호(2021. 3. 17.), 16-19쪽. 원직복직·원상회복이 불가능하는 경우로 기간 만료나 정년 이외에도 폐업이 언급되었다(17쪽).

직복직이 불가능해진 경우에는 구제를 받지 못하고 있음. 이에 원직복직이 불가능해진 경우에도 근로자가 노동위원회의 부당해고 구제절차를 통해 금전보상을 받을 수 있도록 근거를 마련하는 것임.”이라고 개정이유(법령정보센터)를 밝히고 있다.

이상의 입법과정에서 살펴보았듯이 입법자가 입법을 구상하면서 2020년 전원합의체 판결의 취지를 수용하되 사안 그대로를 입법한 것이 아님을 확인할 수 있다. 법원은 개별 사례에 규범을 현실화하는 것일 뿐 보편적으로 적용할 새로운 규범을 창출하는 것은 입법자의 몫이기 때문이다. 근로기준법 제30조 제4항의 입법으로 이제 법관의 법형성(Rechtsfortbildung) 영역에서 법발견(Rechtsfindung)의 영역으로 옮겨갔다고 볼 수 있다.

국회에서의 심사과정 및 최종 개정안을 통해 확인할 수 있는 입법 취지와 시사점은 다음과 같다.

무엇보다도 근로기준법 제30조 제4항의 입법 취지는 앞서 여러 차례 언급되었듯이 ‘원직복직이 불가능해진 경우에도 근로자가 노동위원회의 부당해고 구제절차를 통해 금전보상을 받을 수 있도록 근거’를 마련함으로써 구제의 실효성을 제고하는 것이다. 이러한 의미에서 근로기준법 제30조 제4항을 ‘원직복직 등이 불가능한 경우의 금전보상제도’로 명명하는 것이다.

둘째, 분쟁의 대상 즉 구제신청의 대상을 ‘해고’에 한정하지 않고 ‘해고 이외의 경우’임을 명백히 하였다. 국회 환경노동소위의 심사과정에서 해고 이외의 경우는 주로 정직, 감봉이 거론되었는데, 정직이나 감봉으로 인해 받지 못하거나 감액당한 임금 상당액을 지급받을 필요가 있기 때문이다.

셋째, 근로기준법 제30조 제4항은 ‘원직복직 등이 불가능한 경우’에 대해 2020년 전원합의체 판결에서 명시한 바 있는 ‘근로계약기간의 만료, 정년의 도래 등’으로 규정하였고, 입법 발의안 및 국회에서의 심사과정에서 언급된 또 다른 원직복직 등이 불가능한 경우는 ‘사업의 폐업’이다.³³⁾ 이는 예시이므로 사안에 따라 판단해야 하고, 노동위원회는 부당

33) 앞의 각주 국회회의록 참조.

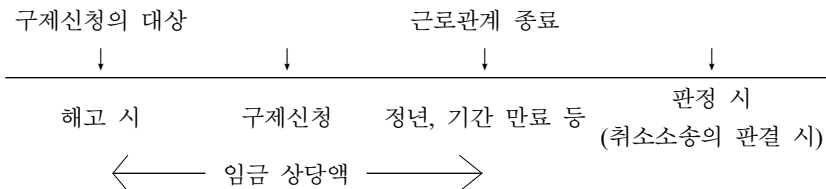
해고 등이 성립하면 부당해고 및 부당징계(정직·감봉 등)가 없었다면 근로관계가 종료할 때(원직복직 및 원상회복이 불가능한 경우)까지 해고와 정직이나 감봉 등으로 인해 받지 못하거나 감액당한 임금 상당액의 지급을 명할 수 있다.

마지막으로 근로기준법 제30조 제4항은 ‘부당해고 등의 효력을 다두고 있을 것’을 요건으로 규정하지 않았으므로 부당해고 등의 구제신청 당시 근로관계가 종료된 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다(이와 관련된 논란은 후술한다). 즉 위 규정 어디에도 ‘부당해고 등 구제절차 도중’에 있을 것을 명시하지 않았을 뿐만 아니라 입법 논의과정에서도 이에 대한 언급은 전혀 없었다. 이는 입법홀결(Gesetzeslücke)이 아니라 입법자가 이를 구별하여 달리 취급하지 않고 임금 차액이나 임금 상당액 지급의 구제명령을 받을 필요가 있는 경우를 전제하는 규정으로 보아야 한다.

4. 근로기준법 제30조 제4항의 해석과 2020년 전원합의체 판결의 적용

2020년 전원합의체 판결의 요지는 ‘해고의 효력을 다투던 중’에 원직복직이 불가능하게 된 경우, 즉 ‘정년에 이르거나 근로계약기간이 만료하는 등의 사유’로 근로관계가 종료된 경우에도 해고기간 중 임금 상당액을 구할 독자적 이익이 있다는 것으로 축약할 수 있다. 이를 구체적으로 나누어 살펴본다.

<2020년 전원합의체 판결의 적용 대상>



첫째, (구제신청의 대상 내지 분쟁의 대상) 2020년 전원합의체 판결의 사안에서 분쟁의 대상(구제신청의 대상 내지 취소소송의 대상)은 ‘해고’이다. 근로관계의 종료인 ‘(징계)해고’뿐만 아니라 이와 같은 법리는 근로자가 부당징계로 정직기간 중 임금을 받지 못하였거나 부당감봉으로 감액당한 임금 상당액의 손실을 회복하기 위해 부당징계 및 부당감봉 구제신청을 한 경우에도 마찬가지로 적용된다.³⁴⁾ 근로자로서는 여전히 정직이나 감봉으로 인해 받지 못하거나 감액당한 임금 상당액을 지급받을 필요가 있으므로 임금 상당액 지급의 구제명령을 받을 이익이 유지된다고 보아야 하기 때문이다.³⁵⁾ 앞서 살펴보았듯이 2021. 5. 18. 신설한 근로기준법 제30조 제4항에서도 “...근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액에 해당하는 금품(해고 이외의 경우에는 원상회복에 준하는 금품을 말한다)을...”라고 규정함으로써 분쟁의 대상이 해고에만 한정되는 것이 아니라 임금 상당액에 해

34) 대법원 2022. 7. 14. 선고 2021두46285 판결. 이 사안은 정년 후 부당징계 구제신청을 한 경우로 대법원은 “근로자가 부당해고 구제신청을 할 당시 이미 정년에 이르거나 근로계약기간이 만료하는 등의 사유로 근로자의 지위에서 벗어난 경우에는 노동위원회의 구제명령을 받을 이익이 소멸하였다고 봄이 타당하고, 이와 같은 법리는 해고 이외의 징계나 그 밖의 징벌 등에 대한 구제신청에 대하여도 마찬가지로 적용된다.”라고 판시함으로써 구제신청 내지 취소소송의 대상이 해고에 한정하지 않음을 전제하는 것이다.

35) 서울고등법원 2023. 2. 17. 선고 2021누57331 판결(확정) “부당해고 구제신청에 관한 위와 같은 법리(2020년 전원합의체 판결)에 비추어 볼 때, 근로자가 부당징계에 대한 구제신청을 하여 징계의 효력을 다투던 중 근로관계가 종료되어 원직에 복직하는 것이 불가능하게 된 경우에도 ‘해당 징계로 인하여 지급받지 못한 임금’ 상당액을 지급받을 필요가 있다면 그러한 미지급 임금 상당액 지급의 구제명령을 받을 이익이 유지되므로, 구제신청을 기각한 중앙노동위원회의 재심판정을 다룰 소의 이익이 있다고 봄이 타당하다. 그러나 근로자가 부당징계에 대한 구제신청을 하여 중앙노동위원회의 재심판정을 받은 후 그 재심판정에 대하여 제기한 취소소송의 계속 중에 근로관계가 종료된 경우에, ‘해당 징계로 인하여 지급받지 못한 임금’이 없고, 그 밖에 ‘근로관계 종료 후 해당 징계로 인하여 받게 될 법률상 불이익’이 없다면, 구제신청을 기각한 중앙노동위원회의 재심판정을 다룰 소의 이익이 없다고 봄이 타당하다.” 이는 원고가 1, 2차 경고처분에 대한 부당징계 구제신청을 제기한 사안이다.

당하는 금품의 원상회복을 구할 필요가 있는 정직이나 감봉 등의 경우도 포함한다는 것을 명백히 하였다. 그러나 전보·전직과 같은 인사명령이나 견책 등의 징계는 기간 만료 등으로 근로관계가 종료되었으므로 이에 대한 구제명령을 구할 이익은 소멸된다고 보아야 한다.

둘째, (근로관계 종료 원인 내지 원직복직·원상회복이 불가능한 경우) 2020년 전원합의체 판결의 사안은 ‘정년’이고, 이 판결에서 명시적으로 언급한 근로관계 종료의 원인은 “정년에 이르거나 근로계약기간이 만료하는 등의 사유로 원직에 복직하는 것이 불가능하게 된 경우”이다. 위 판결로 변경된 종전 판례 모두 해고의 효력을 다투던 중 근로계약기간의 만료와 임기 만료로 근로관계가 종료된 사안이다. 또한 신설된 근로기준법 제30조 제4항에서도 “근로계약기간의 만료, 정년의 도래 등으로 근로자가 원직복직(해고 이외의 경우는 원상회복을 말한다)이 불가능한 경우”라고 규정하였다. 그렇다면 여기서 근로계약기간 만료와 정년 이외에 ‘등’에 해당하는 원직복직·원상회복이 불가능한 경우가 어떠한 것이 있는지 살펴보자.

2020년 전원합의체 판결이 기존 판례의 입장(“종래 대법원은…해고의 효력을 다투던 중 사직하거나 정년에 도달하거나 근로계약기간이 만료하는 등의 이유로 근로관계가 종료한 경우”)을 언급할 때 ‘사직’이 언급되어 사직에도 이와 같은 법리가 적용될 수 있을지 의문의 여지가 있다. 사직에 위와 같은 법리를 적용하여 구제이익이 있다고 보기 위해서는 적어도 ‘해고의 효력을 다투던 중이거나 부당징계 등의 효력을 다투던 중 해고 내지 징계의 정당성 여부에 대해서는 판정 및 판결에 맡기고 장래를 향해 사직’한다는 의사표시를 명시적으로 한 때에 한정하여 구제이익이 있는지를 종합적으로 판단해야 한다. 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하기 전에 근로자가 자의로 사직하거나 해고의 효력을 다투던 중 해고일로 소급하여 사직하였다면 구제받을 권리를 포기하거나 해고의 수용 또는 합의해지로 근로관계가 종료되었다고 볼 여지가 있기 때문이다.

한편, 해고의 효력을 다투던 중 ‘폐업’한 경우도 위와 같은 법리가 적용될 수 있을지가 문제시된다. 앞서 보았듯이 근로기준법 제30조 제4항

입법 발의안 및 국회에서의 심사과정에서 원직복직 등이 불가능한 경우로 ‘폐업’을 예시로 들었다. 사실상 폐업한 경우 유기적 조직체로서 사업(장)이 존재하지 않으므로 원직복직명령은 실현할 수 없을 것이나 기간 만료 등과 마찬가지로 해고일이나 징계처분일로부터 사실상 폐업으로 인해 원직복직이 불가능하게 된 때까지의 임금 상당액을 구할 이익이 있다고 볼 수 있다. 다만 사용자가 사업체를 폐업하고 이에 따라 소속 근로자를 해고하는 것은 그것이 부당노동행위에서 비롯된 위장폐업이 아닌 한 원칙적으로 기업 경영의 자유에 속하는 것이므로 폐업에 따라 사용자와 근로자 사이의 근로관계도 당연히 종료된다.³⁶⁾ 따라서 분쟁의 대상이 되는 해고가 폐업과정에서 발생한 것이라면 이와 같은 법리는 적용되지 않는 것으로 보아야 한다. 예컨대 사용자가 수익성의 악화 등을 이유로 2022. 12. 말에 폐업하기로 결정하고 청산과정에 돌입하여 2022. 9.부터 순차적으로 근로자들에게 해고를 예고하고, 2022. 10. 1. 해고된 근로자들이 2022. 11. 1. 노동위원회에 구제신청을 하였으나 사업장은 예정대로 2022. 12. 말에 폐업한 경우이다. 이러한 해고는 폐업으로 인해 유발된 것, 즉 최초 구제신청의 대상 자체가 근로관계 종료의 원인인 폐업으로 발생한 것이기 때문이다. 따라서 해고가 없었다면 사실상 근로를 제공할 수 있었는지, 그 기간이 어느 정도인지 등을 종합적으로 고려하여 해고의 효력을 다투던 중 폐업한 것인지, 폐업과정에서 해고가 발생한 것인지 여부를 판단해야 한다. 해고 자체가 폐업으로 발생한 경우라면 대체로 폐업 후에 부당해고 구제신청을 하는 경우가 많을 것이다. 이런 측면에서 보면 해고의 효력을 다투던 중에 폐업되는 경우가 구제이익을 인정받을 가능성이 크다고 볼 수 있다(해고와 폐업 간에 인과관계가 있다고 보이지 않기 때문이다). 그리고 폐업으로 인한 해고라면 구제이익이 없는 경우(‘기각’)가 아니라 사업의 폐업으로 ‘신청하는 구제의 내용을 사실상 실현할 수 없는 경우’(노동위원회규칙 제60조 제1항 제6호)이므로 ‘각하’로 결정해야 한다.

셋째, (구제신청의 시점) 2020년 전원합의체 판결의 사안은 ‘해고의 효력을 다투던 중’이므로 정년으로 근로관계가 종료되기 전에 부당해고

36) 대법원 1995. 10. 12. 선고 94다52768 판결 등

구제를 신청한 것인데, 이와 달리 사용자로부터 해고 등을 당한 근로자가 노동위원회에 구제신청을 하기 전에 이미 계약기간이 만료되거나 정년이 도래하여 근로관계가 종료한 경우에도 위 2020년 전원합의체 판결의 법리가 적용될 것인지 여부가 논란이 되었다.³⁷⁾ 또한 개정 근로기준법 제30조 제4항의 해석도 마찬가지로 논란이 되었는데, 최근 대법원은³⁸⁾ 개정법이나 2020년 전원합의체 판결 모두 부당해고 등의 구제신청당시에 이미 근로관계가 종료된 경우에만 구제이익을 인정한 것이 아니라 구제이익을 부인하였다. 이에 대한 자세한 내용과 검토는 항을 바꾸어 살펴본다.

5. 부당해고 등의 구제신청 당시 근로계약관계가 종료된 경우의 구제이익 인정 여부

1) 최근 대법원 판결

2022. 7. 14. 2개의 대법원 판결{2021두46285 판결과 2020두54852 판결(이하 순차로 ‘대상판결①, 대상판결②’, 통칭하여 ‘대상판결들’이라 한다)}이 선고되었는데 다음과 같은 판단의 논거를 제시하면서 부당해고 등의 구제신청 당시 근로관계가 종료된 경우에는 구제이익이 소멸되었다고 판단하였다.

첫째, 부당해고 등 구제명령제도는 민사소송을 통한 통상적인 권리구제 방법보다 좀 더 신속·간이하며 경제적이고 탄력적인 권리구제수단을 마련하는 데에 그 제도적 취지가 있으므로 ‘부당해고 등 구제신청 당시 이미 근로자의 지위에서 벗어난 경우’에까지 과거 부당해고 등으로 인한 손해를 보상받을 목적으로 행정적 구제절차의 이용을 허용하는 것은 사

37) 이러한 경우까지 구제이익을 확대하는 것은 어렵다는 견해(박은정·권오성, “부당해고구제신청의 구제이익과 소의 이익”, 『이화여자대학교 법학논집』 제24권 제3호 통권 69호, 2020, 375쪽)가 있고, 반면 이를 긍정하는 견해(강선희, “부당해고 구제절차와 소의 이익-대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 판결”, 209쪽)가 있다.

38) 대법원 2022. 7. 14. 선고 2021두46285 판결, 대법원 2022. 7. 14. 선고 2020두54852 판결

용자가 근로자에게 제재로서 가하는 불이익한 처분에 대한 구제라는 부당해고 등 구제명령제도의 본래의 보호범위에 포함되지 않는다.

둘째, 근로기준법은 근로자에게 부당해고 등에 대해 구제신청권을 부여하고 있으므로, 부당해고 등 구제신청 당시 이미 근로계약관계가 종료된 경우에는 더 이상 근로자의 지위에 있다고 볼 수 없으며, 부당해고 등 구제신청을 하기 전에 그 사용자와의 관계에서 근로계약관계가 있었다는 사정만으로 구제신청권을 갖는 근로자의 범위에 포함된다고 해석하기는 어렵다.

셋째, 노동위원회의 구제명령이 내려지면 사용자는 이를 이행하여야 할 공법상의 의무를 부담하고, 이행하지 아니할 경우에는 이행강제금이 부과되며, 확정된 구제명령을 이행하지 아니한 사용자는 형사처벌의 대상이 되므로 이와 같은 경우에까지 근로자의 구제이익을 인정하면 사용자에게 공법상 의무를 지나치게 부과하거나 형사처벌의 범위를 확대하는 결과가 된다.

넷째, 2020년 전원합의체 판결의 사안은 ‘해고의 효력을 다투던 중’이므로 근로자가 부당해고 등 구제신청을 하기 전에 이미 근로자의 지위에서 벗어난 경우에는 위와 같은 법리가 그대로 적용된다고 할 수 없다.

다섯째, 해고의 효력을 다투던 중에 근로계약관계가 종료되었다는 이유로 그 신청인을 구제절차에서 배제하거나 그동안 노동위원회가 진행한 조사나 그 조사결과를 토대로 내린 판정을 근로계약관계가 종료되었다는 이유로 모두 무위로 돌리는 것은 바람직하지 않다고 볼 여지가 있으나, 구제신청 당시 이미 근로계약관계가 종료된 경우에는 그러한 고려를 할 필요성이 크지 않다. 근로계약관계가 종료된 시점을 구제신청 이전과 이후로 구분하여 구제명령을 구할 이익의 존부를 달리 취급하는 것은 충분히 합리적이다.

여섯째, 근로기준법 제30조 제4항은 구제신청 당시 이미 근로계약관계가 소멸하여 근로자의 지위에서 벗어난 경우에까지 구제이익을 인정하여야 한다는 의미로 해석되지 않는다.

2) 평가

먼저 검토할 것은 근로기준법 제30조 제4항이 이와 같은 사안을 예정하지 않은 입법흡결(Gesetzeslücke)이 있는지, 입법흡결이 아니라면 근로기준법 제30조 제4항의 해석으로 위 대상판결들과 같이 부당해고 등의 구제신청 당시 근로관계가 종료된 경우에 구제이익이 소멸되었다고 해석할 수 있는지 여부이다. 물론 위 대상판결들의 사안은 근로기준법 제30조 제4항이 시행되기 전의 것이지만 판결 시 이미 신설 조항이 시행되고 있었으므로 법원은 법적용의 준거로 삼아야 하기 때문이다.

앞서 살펴보았듯이 입법안이나 국회 입법심사과정에서 근로기준법 제30조 제4항이 적용될 사안을 ‘해고 등의 효력을 다두고 있을 것’으로 한정한 사실이나 이러한 사실을 추단할 만한 근거를 어디에서도 발견할 수 없다. 이는 입법자가 의도적으로 침묵하면서 그 공백(흡결)의 보충을 법관의 법형성에 맡긴 것이 아니라 구제신청의 시점에 따라 달리 판단할 필요성이 없었기 때문에 이를 명시하지 않은 것으로 보아야 한다. 입법안, 입법심사과정 전반 및 최종 입법화된 규정을 통해 확인할 수 있는 주된 입법목적과 핵심은 기간 만료나 정년 등으로 근로관계가 종료되어 원직복직·원상회복이 불가능해졌더라도 노동위원회의 부당해고 등의 구제절차를 통해 임금 상당액이나 임금 차액에 해당하는 금품을 지급받을 필요가 있다면 그 부당해고 등의 구제신청에 대하여 구제이익이 없다고 볼 것이 아니라 판단하여 구제명령이나 기각결정을 해야 한다는 것이다 (개정이유 “원직복직이 불가능해진 경우에도 근로자가 노동위원회의 부당해고 구제절차를 통해 금전보상을 받을 수 있도록 근거를 마련하는 것”).³⁹⁾ 부당해고 등의 구제신청 당시 근로관계가 종료되었다고 하여 임

39) 구제이익이 없는 경우 각주23)에서 보았듯이 2021. 10. 1. 노동위원회규칙의 개정으로 ‘각하’에서 ‘기각’으로 변경되었으나 근로기준법 제30조 제4항이 신설된 2021. 5. 18.에 여전히 ‘각하’였으므로 근로기준법 제30조 제1항 1문에 “노동위원회는 근로계약기간의 만료, 정년의 도래 등으로 근로자가 원직복직(해고 이외의 경우는 원상회복을 말한다)이 불가능한 경우에도 제1항에 따른 구제명령이나 기각결정을 하여야 한다.”라고 규정한 것이다. 이와 같이 규정한 취지는 노동위원회가 조사 및 심문을 거쳐 구제명령을 내릴 것인지 기각결정을 할 것인지 판정해야 한다는 것이다.

금 상당액이나 임금 차액에 해당하는 금품을 지급받을 필요가 소멸하는 것이 아니므로 위와 같은 입법목적에 비추어 보면 구제이익은 여전히 인정된다고 판단해야 한다.

설령 입법자의 의도와 상관없이 입법흡결이 발생하여 법관에 의한 법형성이 허용되더라도 법형성의 방법론 측면에서 보면 유추할 사안이지 목적론적 축소할 사안은 아니다. 앞서 간략히 언급하였듯이 본질적으로 같은 것은 같게 취급한다는 원칙에 따라 법적용의 범위를 확대하는 것이 유추인 반면, 본질적으로 다른 것은 다르게 취급한다는 원칙에 따라 해당 규범의 적용범위를 축소시키는 것이 목적론적 축소이다. 즉 입법흡결을 보충하는 법형성의 일종으로서 목적론적 축소는 규범의 목적이거나 기본사고로 볼 때 너무 넓게 파악된 규범을 그 목적에 적합하게 축소 적용하는 것을 말한다.⁴⁰⁾ 이와 같은 법형성의 방법론에 비추어 보면 부당해고 등의 구제신청을 하여 이를 닦고 있던 중에 원직복직 등의 불가능해진 경우이든 그렇지 않은 경우이든 금전보상(임금 차액이나 임금 상당액에 해당하는 금품)을 구할 구체적인 필요라는 측면에서는 본질적으로 같다. 따라서 원직복직 등이 불가능해진 경우에도 금전보상을 할 수 있는 근거로서 마련된 근로기준법 제30조 제4항을 유추적용하여 동일한 법적 효과를 부여해야 한다.

입법흡결이 아니라면 근로기준법 제30조 제4항의 해석상 부당해고 등의 구제신청 당시 근로관계가 종료된 경우도 포함할 수 있는지는 앞서 여러 차례 서술하였듯이 연혁적 해석이나 목적론적 해석을 통해서도 구제신청 시점에 따라 판단을 달리할 필요가 없는 것으로 해석하는 것이 논리적이다.

한편 위 대상판결들은 2020년 전원합의체 판결의 사안이 해고의 효력을 닦았던 것이므로 그렇지 않은 경우에까지 그대로 적용할 수 없다고 판단하였다. 그러나 오히려 위 전원합의체 판결의 요지를 보면 “해고기간 중의 임금 상당액을 지급받을 필요가 있다면 임금 상당액 지급의 구제명령을 받을 이익이 유지된다.”라고 판시하였듯이 이 판결의 대상 사

40) 김영환, “법학방법론의 관점에서 본 유추와 목적론적 축소”, 『법철학연구』 제12권 제2호, 2009, 9쪽 이하 참조.

안 자체가 ‘해고의 효력을 다투던 중’이었던 것일 뿐 이것만을 전제한 것으로 보이지 않는다. 또한 이와 같이 ‘전원합의체’로 판단하여 구제이익을 인정한 주된 목적은, 임금을 지급받기 위해 임금청구소송 등의 민사소송절차를 통해 해결될 수 있다는 이유를 들어 구제이익을 부인한 중전 판결을 폐기하기 위한 것임을 되새길 필요가 있다. 즉 대상판결들과 같이 판단한다면 근로자는 또다시 해고기간 중의 임금을 지급받기 위해 부당해고라는 판단을 구하면서 임금청구소송 등 민사소송절차를 통하여 해결해야 하는 상황(중전 판결의 상황)에 처하게 되어 2020년 전원합의체 판결의 취지와 부합하지 않게 된다.

특히 해고기간 중의 임금을 지급받기 위한 것도 있지만 여기서 더 나아가 기간 만료 내지 정년 등의 근로관계 종료에 대해 갱신기대권 및 정년 후 재고용 기대권 등을 주장하며 구제신청을 하는 경우 선행하는 해고나 정직 등의 정당성 여부에 따라 갱신되거나 재고용될 수 있으므로 이의 판단을 받을 필요가 있다. 예컨대 해고나 징계처분을 받지 않았다면 요건을 충족하여 근로계약이 갱신되거나 정년 후 재고용될 수 있는 경우라면 해고나 징계처분의 정당성에 대해 판단해야 한다. 정직처분을 받고 근로계약기간이 만료된 후에 근로자가 노동위원회에 부당정직 및 부당해고 구제신청을 하는 경우라든지 해고되어 정규직으로 전환되지 못하고 근로계약기간이 만료된 경우 기간 만료 후에 앞선 해고에 대한 구제신청과 근로계약기간 만료에 대한 구제신청을 하는 경우 등이다. 이와 같은 사례에서 위 대상판결들의 판단에 따르면 정직이나 해고는 구제이익이 없어 기각되더라도 근로계약기간 만료의 정당성 판단(갱신기대권 및 합리적 이유 유무)에서 그 전제로서 정직이나 해고의 정당성을 판단해야 한다. 따라서 정직기간이나 해고기간에 대한 임금 상당액을 지급받을 필요뿐만 아니라 근로계약기간 만료 등의 부당해고 구제신청과 관련하여 정직이나 해고에 대한 노동위원회의 공권적 판단을 구할 구체적인 필요가 있으므로 구제이익은 인정되어야 한다(대상판결들의 입장에 따르면 기간 만료 등으로 근로관계가 종료된 경우 정직기간이나 해고기간에 대한 임금청구소송은⁴¹⁾ 가능하나 해당 정직이나 해고에 대해

41) 임금청구권이 성립하는지 여부를 판단하기 위한 전제로서 해당 정직이나

무효 확인을 구할 이익이 없다고 볼 가능성이 크다⁴²⁾). 위와 같은 내용에 비추어 보면 민사소송과 노동위원회 구제절차로 운영하는 것은 ‘근로자 보호나 절차경제적 측면’에서 보면 오히려 불합리하고 비효율적이며, 2020년 전원합의체 판결(“민사소송과 별개로 신속·간이한 구제절차 및 이에 따른 행정소송을 통해 임금 상당액의 손실을 회복할 수 있도록 한 것이 부당하고 구제명령제도의 취지에 부합한다.”)과도 배치된다.

다른 한편 대상판결들은 근로기준법은 ‘근로자’에게 부당하고 등에 대해 구제신청권을 부여하고 있으므로 구제신청 당시 이미 근로관계가 종료된 경우에는 더 이상 근로자의 지위에 있다고 볼 수 없으므로 구제신청권을 갖는 근로자로 해석하기 어렵다는 논거를 내세웠다. 구태여 참언하면 근로기준법 제23조 제1항 및 제28조는 해고(해고제한법리가 적용되는 기간 만료, 정년 등의 근로관계 종료 포함)된 근로자가 부당해고임을 주장하며 ‘근로자’의 지위를 회복하기 위해 구제를 신청하는 것이므로 근로자의 지위에 있는 사람은 오히려 부당해고의 구제를 신청할 수 없다(근로기준법 제28조 제1항은 부당해고 등을 당한 근로자가 노동위원회에 구제를 신청할 수 있도록 규정하였다).⁴³⁾

3) 사안의 해결

대상판결①의 사안을 보면, 근로자X가 사용자로부터 2018. 12. 28.(금) 1개월의 정직처분을 받았으나, 2018. 12. 31.(월) 정년에 도달하였고, 2019. 1. 3. 노동위원회에 부당정직 구제신청을 한 사안이다. 원심(대전고등법원 2021. 6. 18. 선고 2020누12481 판결)은 “부당정직 구제신청 당시 이미 정년에 이른 원고에게도 정직으로 인해 받지 못한 임금 상당액을 지급받을 필요가 있으므로, 정직기간 중의 임금 상당액 지급에 관

해고의 정당성을 판단하는 구조이다.

42) 대법원 2007. 12. 28. 선고 2006다33999 판결 등

43) 이외의 비판적 내용에 대해서는 장영석, “정년 도래, 근로계약기간 만료, 폐업 등 이후 부당해고 등 구제신청과 구제이익-대법원 2022. 7. 14. 선고 2021두46285 판결-”, 월간 『노동리뷰』 2022년 9월호(통권 제210호), 한국노동연구원, 2022, 115-117쪽 참조.

한 구제명령을 받을 이익이 있다고 보아야 한다.”라고 하였으나 대법원은 앞서 언급한 취지로 원심을 파기·환송하였다. 대법원이 내세운 논거에 대해서는 위와 같은 이유로 동의할 수 없으나 구제이익이 없다는 결론에는 찬동할 수 있다. 정직처분을 받고 정년에 도달하여 퇴직할 때까지 정직처분이 없었더라면 근로제공을 통해 받을 수 있었던 임금 상당액은 최대 1일분(12. 31.)이고, 이의 지급 여부 정확히 확인되지 않으나 소송과정에서 논란이 된 것은 정직처분으로 제공하지 못한 근로제공에 상응하는 임금 상당액이 아니라 정직처분으로 인해 감액된 성과급(정직기간이 있는 직원에 대한 성과연봉의 감액한다는 직원보수규정)이었다. 실제 쟁점은 감액된 성과급의 지급을 둘러싼 구제이익의 인정 여부라고 할 수 있다. 근로기준법은 제30조 제4항 2문은 “이 경우 노동위원회는 부당해고등이 성립한다고 판정하면 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액에 해당하는 금품(해고 이외의 경우에는 원상회복에 준하는 금품을 말한다)을 사업주가 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다.”라고 규정한 사실에 비추어 보면 구제이익을 인정하기 위해서는 해고나 정직과 같은 경우 해고나 정직처분이 없었더라면 근로제공을 통해 받을 수 있었던 임금 상당액이고, 감봉의 경우 감봉처분이 없었더라면 실제 받았을 임금 차액(감봉처분을 받은 때부터 근로관계 종료 시까지 실제 감액된 임금)에 상당하는 금품이다. 따라서 대상판결 ①의 사안과 같이 정직처분이 없었더라도 근로제공을 통해 받을 수 있었던 임금 상당액이 없거나 경미한 경우에까지 노동위원회의 구제절차를 유지할 필요는 없다고 보아야 하고, 감액된 성과급은 성과급청구소송을 통해 해결할 수 있을 것이다.

대상판결②의 사안을 보면, 육군○○사단(대한민국)은 사단 간부이발소의 수익성이 악화되자 폐쇄하기로 결정하고 사단 간부이발소에서 미용업무를 수행하는 근로자B에게 2018. 4. 27. 해고예고를 통보하고, 2018. 5. 31. ○○사단 간부이발소는 폐쇄되었으며 같은 날 근로자B도 해고되었다. 근로자B는 2018. 6. 15. 노동위원회에 부당해고 구제신청을 하였으나 지방노동위원회는 근로자B를 복직시킬 사업장이 없어져 구제이익이 소멸하였다는 이유로 근로자B의 구제신청을 각하하였고, 중앙노

동위원회와 행정법원은 초심 판정과 같이 판단하였으나 원심(서울고등법원 2020. 10. 30. 선고 2020누34591 판결)은 위 대상판결①의 원심과 같은 이유로 1심 판결을 취소하였다. 그러자 대법원은 앞서 언급한 취지로 원심을 파기·환송하였다. 이 경우도 대법원의 결론에 일응 수긍이 가나 판시 내용과 같은 논거에는 찬동하기 어렵다. 앞서 Ⅲ. 5.에 서술하였듯이 근로기준법 제30조 제4항은 해고나 정직 등의 처분에 대한 구제신청이 폐업으로 인해 원직복직이나 원상회복이 불가능한 경우에 적용되는 반면, 해고에 대한 구제신청 자체가 폐업으로 인해 발생한 것이라면 이 규정은 적용되지 않는다고 보아야 한다. 따라서 대상판결②의 사안이 사업의 폐업으로 근로자B가 해고된 것이라면 결론적으로 각하(‘신청하는 구제의 내용을 사실상 실현할 수 없는 경우’) 판결을 해야 할 것으로 보인다. 다만 이 사안의 경우 ○○사단 간부이발소 폐쇄가 ‘폐업’인지 아니면 ‘사업의 일부 폐지’인지를 판단해야 하고, 폐업이라면 각하할 것이나 사업의 일부 폐지라면 근로기준법 제24조가 적용되어 경영상 해고의 요건을 갖추어야 한다. 파기환송심(서울고등법원 2023. 6. 21. 선고 2022누53268 판결)의 판결문을 입수하지 못해 이에 대한 심리를 했는지는 확인되지 않으나 항소기각한 사실에 비추어 보면 ○○사단 간부이발소를 별도의 ‘사업’으로 보아 이의 폐쇄를 ‘폐업’으로 판단한 것으로 보인다.

위 대상판결들의 결론에 따라 기간 만료나 정년이 도래하기 전 그리고 3개월의 제척기간 내에 서둘러 노동위원회에 구제를 신청하면 논란의 여지 없이 법의 적용을 받게 되므로 현실에 미치는 파장이 그리 크지 않을 수도 있다. 그러나 이러한 현실적 판단과 별개로 위와 같은 판단이 법체계적인 관점에 부합하는지, 논리적인지에 대해 강한 의구심이 있으므로 다시 판단해볼 것을 기대한다.

IV. 사실상 무기계약 법리의 등장과 한계

1. 사실상 무기계약 법리의 등장

기간제근로자의 고용종료에 대한 보호 법리로 처음 등장한 것은 사실상 무기계약 법리인데, 이러한 판례 법리는 1994년에 등장하였으나 근로계약기간에 대한 1996년 전원합의체 판결이 선고되면서 탄력을 받았다고 볼 수 있다. 대법원 1994. 1. 11. 선고 93다17843 판결은 최초로 “기간을 정하여 채용된 근로자라고 할지라도 장기간에 걸쳐서 그 기간의 갱신이 반복되어 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우에는 사실상 기간의 정함이 없는 근로자의 경우와 다를 바가 없게 되는 것이고, 그 경우에 사용자가 정당한 사유 없이 갱신계약의 체결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효이다.”라고 판시하였는데, 이 판결의 경우 ‘기간제 근로계약이 장기간 반복 갱신되었다는 사실’이 근로계약기간을 정한 것이 형식에 불과하다는 사정의 주된 인정 근거였다.⁴⁴⁾

이로부터 2년 뒤에 1996년 전원합의체 판결이 선고되자 이를 원용하여 대법원(1998. 1. 23. 선고 97다42489 판결)은 “근로계약기간을 정한 경우에 있어서 근로계약 당사자 사이의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 만료함에 따라 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고, 다만 단기의 근로계약이 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 예외적인 경우에 한하여 비록 기간을 정하여 채용된 근로자일지라도 사실상 기간의 정함이 없는 근로자와 다를 바가 없게 되는 것이고 그 경우에 사용자가 정당한 사유 없이 갱신계약의 체결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효로 된다.”라고 판시하였다.⁴⁵⁾ 기간

⁴⁴⁾ 이후에 대법원 1995. 7. 11. 선고 95다9280 판결이 위 판결을 원용하였으나 사실상 무기계약임을 부인하였다.

⁴⁵⁾ 이 판결은 위 대법원 93다17843 판결과 같은 대학교에서 같은 지위(시간강사)에 있는 근로자에 대한 판단이었으나 결론을 달리하여 사실상 무기계약임을 부인하였다.

제 근로계약을 체결한 경우 기간의 만료로 근로관계가 당연히 종료되는 것이 원칙이나, ‘단기의 근로계약이 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써 그 정한 기간이 단지 형식에 불과’하게 된 경우를 예외로 인정하는 구조이다.

이와 같은 판단기준은 대법원 1998. 5. 29. 선고 98두625 판결에서 “근로계약을 체결하면서 기간을 정한 근로계약을 작성한 경우 그 근로계약이 계약서의 문언에 반하여 기간의 정함이 없는 근로계약이라고 하기 위해서는 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 당사자의 진정한 의사, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정되어야 할 것”이라며 장기간의 반복 갱신 여부 외 다른 판단요소를 내세웠다.

갱신기대권 법리를 최초로 인정한 판례가⁴⁶⁾ 2005년에 나오면서 법원은 위 판단기준을 정식화시켰는데, 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673 판결은 “근로계약기간을 정한 경우에 있어서 근로계약 당사자 사이의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 만료함에 따라 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료된다. 그렇지만 한편, 기간을 정한 근로계약을 작성한 경우에도 예컨대 단기의 근로계약이 장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써 그 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우 등 계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 당사자의 진정한 의사, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호법규 등을 종합적으로 고려하여 그 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정되는 경우에는 계약서의 문언에도 불구하고 그 경우에 사용자가 정당한 사유 없이 갱신계약의 체결을 거절하는 것은 해고와 마찬가지로 무효로 된다고 보아야 한다.”라고 판시함으로써 판례 법리로 자리잡게 되었다.⁴⁷⁾

46) 대법원 2005. 7. 8. 선고 2002두8640 판결

47) 대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두16901 판결은 원칙의 실시 부분을 달리 표현하였다(“근로계약기간을 정한 근로계약을 작성한 경우 처분문서인 근

2. 사실상 무기계약 법리의 의의와 한계

1년을 초과하여 근로계약기간을 정할 수 없도록 한 구 근로기준법 제 23조는 강행규정이 아니라 임의규정이므로 1년을 초과하여 근로계약기간을 정하더라도 유효하다는 1996년 전원합의체 판결에 따라 더 이상 기간제 근로계약의 고용종료를 보호할 장치가 없어지면서 사실상 무기계약 법리에 대한 주장이 탄력을 받게 되었다. 그러나 이러한 기간제근로자의 주장에도 불구하고 법원에서 쉽사리 인정받기 어려운 측면이 있었다.

법원(法源, Rechtsquelle)으로서의 근로계약은 근로자와 사용자 사이의 법적 분쟁을 해결하기 위해 법관이 기준으로 삼아야 할 재판규범의 존재 형식인 법인식원천(Rechtserkenntnisquelle)임과 동시에 근로관계(근로자와 사용자 간에 권리와 의무)의 법적 내용을 결정하는 근거(Arbeitsverhältnisquelle)이기도 하다. 판례는 법관에 의해 법해석의 형식이나 법형성의 형식으로 생성될 수 있으나 법원성(Rechtsquelle)을 갖지 않는다. 이러한 이유로 법관은 당사자가 기간을 정하여 근로계약을 체결한 경우 이와 같은 근로계약서의 문언에 반하여 기간의 정함이 없는 근로계약으로 인정하는 데에 한계가 있을 수밖에 없다. 또한 이러한 이유로 제반 사정을 종합하여 근로계약기간을 정한 것이 형식에 불과하다는 사정이 인정되어야 한다는 엄격한 기준을 제시한 것으로 보인다.

판례 법리에 따르면 사실상 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결할 것으로 보기 위해서는 첫째, ‘장기간에 걸쳐서 반복하여 갱신됨으로써’ 정한 기간이 단지 형식에 불과하게 된 경우이고, 둘째는 ‘계약서의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 기간을 정한 목적과 당사자의

로계약서의 문언에 따라 특별한 사정이 없는 한 근로자와 사용자 사이에는 기간의 정함이 있는 근로계약을 맺었다고 보아야 하고, 이 경우 근로계약기간이 끝나면 그 근로관계는 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료함이 원칙’). 법원에 따라 이 판결을 원용하는 경우도 많다. 여기서 처분문서란 증명하고자 하는 법률상의 행위가 그 문서 자체에 의하여 이루어진 경우의 문서를 뜻하는 것으로 행정처분서, 판결문, 어음·수표 등의 유가증권, 계약서·차용증서, 유언서 등을 그 예로 들 수 있다.

진정한 의사, 동종의 근로계약 체결방식에 관한 관행 그리고 근로자보호 법규 등을 종합적으로 고려'하여 기간의 정함이 단지 형식에 불과하다는 사정이 인정되는 경우이다. 첫 번째의 경우는 사용기간을 제한한 기간제 법의 시행으로 장기간 반복 갱신이 가능하지 않고, 사용기간 제한의 예외에 해당하는 사람에게 제한적으로 적용될 것이므로 적용대상 영역이 축소되었다고 볼 수 있다. 두 번째의 경우는 당사자의 진정한 의사는 기간의 정함이 없는 근로계약의 체결이나 형식적으로 기간제 근로계약을 체결한 사정이 인정되어야 하는데, 법원의 입장에서 보면 '당사자의 진정한 의사'를 좇아 법적 효력을 부여하는 것이 쉽지 않을 것으로 보인다. 이러한 한계에도 불구하고 사실상 무기계약 법리는 기간제근로자의 고용종료에 대한 어떠한 보호장치도 없을 때 그 기능을 담당하였던 측면, 여전히 형식적 기간제 근로계약의 존재 그리고 기대권 법리의 탄생에 단초를 제공하였다는 측면에서 결코 낮게 평가될 수 없을 것이다.

V. 계속 고용 기대권 법리의 전개와 판단구도

1. 근로계약 갱신기대권 법리의 등장과 외연의 확대

사실상 무기계약 법리는 매우 제한적으로 적용되는 한계가 있어 갱신 기대권 법리의 등장과 더불어 이의 주장이 줄어드는 양상을 보이고 있다. 물론 여전히 주위적으로 사실상 무기계약임을 주장하고, 예비적으로 갱신기대권을 주장하는 경우도 있다.

2005년 한국문화정책개발원 사건에서⁴⁸⁾ 갱신기대권을 최초로 언급하였는데, “임용의 근거가 된 법령 등의 규정이나 계약 등에서 임용권자에게 임용기간이 만료된 근로자를 재임용할 의무를 지우거나 재임용절차 및 요건 등에 관한 근거규정을 두고 있어 근로자에게 소정의 절차에 따라 재임용될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는 사용자가 그 절차에 위반하여 부당하게 근로자를 재임용에서 제외하는 것은

48) 대법원 2005. 7. 8. 선고 2002두8640 판결

실질적으로 부당해고와 동일시할 수 있”다고 판시하였다. 이는 계약기간을 정하여 임용된 근로자의 경우 그 기간이 만료되었음에도 재임용될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정된다면 이는 부당해고와 동일시할 수 있으므로 근로자로서는 임용기간이 만료된 후에도 재임용에서 제외된 조치의 유효 여부를 다룰 법률상 이익을 가진다는 판단을 전제로 재임용 거부의 정당성을 판단한 사안이다. 그리고 대법원은 해당 사안(재임용 요건 등에 대한 근거규정을 두고 있는 경우)에 한정하여 판단한 것으로 일반적인 판단기준을 제시한 것은 아니었다. 그러나 이 판결은 처음으로 기대권(‘재임용될 수 있으리라는 정당한 기대권’)을 인정하면서 기간제 근로계약의 기간 만료에 대해 사실상 무기계약 법리 외에 해고 제한법리를 적용한 것으로 큰 의의가 있고, 이후 기대권 법리의 정립 및 외연의 확대에 단초를 제공하였다고 평가할 수 있다.

주지하다시피 갱신기대권 법리는 2011년 서울특별시시설관리공단 사건의 판결(대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결)을 통해 판례 법리로 정립되었고, 이후 이러한 판례 법리는 무기계약직(정규직) 전환 기대권, 고용승계기대권, 정년 후 재고용 기대권 및 정규직 전환 채용 기대권으로 외연이 확대되었다.⁴⁹⁾ 정년 후 재고용 기대권과 정규직 전환 채용 기대권은 기간제근로자의 고용종료는 아니므로 필요한 범위 내에서 언급하도록 한다.

2. 계속 고용 기대권의 판단구도

갱신기대권, 정규직(무기계약직) 전환 기대권 및 고용승계 기대권의 판결요지를 살펴보면 아래와 같다.

- 근로계약 갱신기대권: 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결
 “기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되고 근로계약을 갱신하지 못하면 갱신거절의 의사표시가 없어도 그 근로자는 당연 퇴직되

49) 각주7)에 명시한 판례들이다.

는 것이 원칙이다(근로관계 종료, A). 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간 만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나(명시적 규정, B-1), 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성(명시적 규정이 없는 경우, B-2)되어 있어 근로자에게 그에 따라 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우(계속 고용에 대한 기대권, B)에는 사용자가 이에 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고(해고제한법리의 적용, C), 이 경우 기간 만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다고 할 것이다(법적 효과, D).”(괄호는 필자가 덧붙임, 이하 같음)

○ 정규직(무기계약직) 전환 기대권: 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 판결

“기간을 정하여 근로계약을 체결한 근로자의 경우 그 기간이 만료됨으로써 근로자로서의 신분관계는 당연히 종료되는 것이 원칙이다(근로관계 종료, A). 그러나 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간제근로자의 계약기간이 만료될 무렵 인사평가 등을 거쳐 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 취지의 규정을 두고 있거나(명시적 규정, B-1), 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환에 관한 기준 등 그에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된다는 신뢰관계가 형성(명시적 규정이 없는 경우, B-2)되어 있어 근로자에게 기간의 정함이 없는 근로자로 전환될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우(계속 고용에 대한 기대권, B)에는 사용자가 이를 위반

하여 합리적 이유 없이 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환을 거절하며 근로계약의 종료를 통보하더라도 부당해고와 마찬가지로 효력이 없고(해고제한법리의 적용, C), 그 이후의 근로관계는 기간의 정함이 없는 근로자로 전환된 것과 동일하다고 보아야 한다(법적 효과, D).”

○ 고용승계 기대권: 대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결⁵⁰⁾

“도급업체가 사업장 내 업무의 일부를 기간을 정하여 다른 업체(이하 ‘용역업체’라고 한다)에 위탁하고, 용역업체가 위탁받은 용역업무의 수행을 위해 해당 용역계약의 종료 시점까지 기간제근로자를 사용하여 왔는데, 해당 용역업체의 계약기간이 만료되고 새로운 용역업체가 해당 업무를 위탁받아 도급업체와 사이에 용역계약을 체결한 경우, 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하여 새로운 근로관계가 성립될 것이라는 신뢰관계가 형성되었다면, 특별한 사정이 없는 한 근로자에게는 그에 따라 새로운 용역업체로 고용이 승계되리라는 기대권이 인정된다(계속 고용에 대한 기대권, B). 이와 같이 근로자에게 고용승계에 대한 기대권이 인정되는 경우 근로자가 고용승계를 원하였는데도 새로운 용역업체가 합리적 이유 없이 고용승계를 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없다(해고제한법리의 적용, C). 이때 근로자에게 고용승계에 대한 기대권이 인정되는지 여부는(계속 고용에 대한 기대권, B) 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항을 포함하고 있는지 여부를 포함한 구체적인 계약내용(판단요소^{a)}), 해당 용역계약의 체결 동기와 경위, 도급업체 사업장에서의 용역업체 변경에 따른 고용승계 관련 기존 관행, 위탁의 대상으로서 근로자가 수행하는 업무의 내용, 새로운 용역업체와 근로자들의 인식 등(그 밖의 판단요소^{b)}) 근로관계 및 해당 용역계약을 둘러싼 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

위 판결요지를 요약·정리하면, 근로계약기간 만료나 아웃소싱업체의

50) 이에 대한 평석으로 강선희, “용역업체 등의 변경 시 고용승계기대권-대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결-”, 월간 『노동리뷰』 2021년 7월호 (통권 제196호), 한국노동연구원, 2021.

변경 등을 원인으로 한 근로관계 종료는 원칙적으로 해고는 아니나(근로관계 종료, A) 근로자에게 근로관계가 계속될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우(계속 고용에 대한 기대권, B)에는 이러한 기대권을 침해하여 사용자가 합리적 이유 없이 계속 고용을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 근로자에게 효력이 없다(해고제한법리의 적용, C). 이에 따른 법적 효과는 침해되는 기대권을 실현시키는 방향으로 나타나므로 갱신기대권의 경우는 ‘기간 만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일’한 효과, 정규직 전환 기대권의 경우는 ‘기간의 정함이 없는 근로자로 전환된 것과 동일’한 효과, 고용승계 기대권의 경우는 새로운 용역업체로 고용이 승계되어 새로운 근로관계가 성립되는 효과가 발생한다.

다시 말하면 계속 고용에 대한 기대권 법리는 근로계약기간 만료, 아웃소싱업체의 변경과 같은 사업주의 변경 등을 원인으로 한 근로관계 종료는 원칙적으로 해고는 아니나 근로관계가 계속될 것이라는 정당한 기대권이 형성되어 있다면 갱신 거절이나 승계 거부 등의 근로관계 종료는 근로자에게 해고와 마찬가지로의 효과가 나타나므로 예외적으로 근로자의 근로관계를 보호할 목적으로 해고제한법리를 유추적용하는 판례 법리이다. 이렇듯 기대권 법리는 유추의 방식을 통한 법관의 법형성으로 근로관계 종료에 대한 예외로서 탄생한 것이기 때문에 지나치게 확대할 수 없다는 태생적 한계가 있다. 법리상 원칙과 예외가 바뀔 수는 없더라도 법원은 그간 사용자의 기간제 근로계약의 남용으로부터 근로자의 근로관계를 보호하기 위해 근로관계의 밀도(기간제로의 갱신, 정규직으로 전환, 새로운 사용자와의 근로관계 형성)나 근로자의 보호필요성의 정도에⁵¹⁾ 따라 기대권의 인정 폭을 달리하였다고 평가할 수 있다.

‘정당한 기대권이 인정되는 경우’에 대한 판단기준을 보면, 갱신기대

51) 계속 고용에 대한 기대권 법리 중 정년 후 재고용 기대권(대법원 2023. 6. 29. 선고 2018두62492 판결)의 경우 다른 기대권과 달리 더욱 엄격한 판단 요소(‘재고용하여야 한다는 취지의 규정에 있는 경우에 준하는 정도의 재고용 관행’)를 내세운 것으로 보이는데 이는 정규직으로서 정년까지 근로한 근로자의 경우 다른 기대권의 기간제근로자에 비해 상대적으로 보호필요성이 낮다고 본 것으로 보인다.

권과 정규직 전환 기대권은 명시적 규정(B-1)이 있거나 (B-1이 없더라도) 제반 사정을 통해 근로관계가 계속될 것이라는 신뢰관계가 형성(B-2)되어 있다면 기대권이 인정된다.⁵²⁾ 따라서 명시적 규정이 있다면 더 나아가 신뢰관계의 형성 여부를 따질 필요 없이 기대권이 인정되고, 이때의 갱신 거절 등의 합리적인 이유는 명시적 규정에서 정한 절차 및 요건이 될 것이다.

반면 고용승계 기대권 경우 앞의 2가지 기대권과 달리 첫째, 고용을 승계하기로 하는 약정(판단요소㉔)은 그 밖의 판단요소㉕와 더불어 기대권 인정의 판단요소로 병렬적으로 열거되고, 둘째, ‘새로운 용역업체와 근로자들의 인식’을 판단요소로 제시하였으며, 셋째, 부가적으로 ‘특별한 사정이 없’어야 한다.⁵³⁾ 첫째와 관련된 판례의 태도에 대해 고용승계와 관련한 명시적 약정만으로 새로운 용역업체에 고용승계의무를 인정하기 어렵다거나, 명시적 약정이 없는 경우 관행 등으로만 고용승계의무를 인정하기 어렵다고 본 것은 아닌지라는 의구심을 제기한 바 있다.⁵⁴⁾ 이후 명시적 약정 없이 관행 등의 제반 사정만으로 고용승계의무를 인정한 대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결로⁵⁵⁾ 이와 같은 의구심의 일부 덜어낸 듯하다. 요컨대 새로운 용역업체가 종전 용역업체 소속 근로자에 대한 고용을 승계하기로 하는 조항 등(명시적 규정이나 약정)이 있다면, 이를 부인할 만한 특별한 사정이 없는 한 새로운 사용자는 고용승계의무를 부담한다고 판단해야 한다고 본다. 이때 부인할 만한 특별한 사정은 그러한 규정이나 약정이 규범력이 없어 형식에 불과하다는

52) 정년 후 재고용 기대권도 동일한 판단구도를 가지고 있으나 부가적으로 기대권을 부인할 만한 ‘특별한 사정이 없’을 것을 요구하는 측면에서 차이가 있다.

53) 기대권을 부인할 만한 ‘특별한 사정’에 대한 자세한 내용은 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 『노동법포럼』 제 38호, 노동법이론실무학회, 2023, 176쪽 이하 참조.

54) 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 176쪽 이하 참조.

55) 이에 대한 평석으로 강선희, “용역업체 등의 변경 시 관행 등을 근거로 한 고용승계기대권 및 두 가지 의문(대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결)”, 월간 『노동리뷰』 2021년 9월호(통권 제198호), 한국노동연구원, 2021.

사정을 말하며, 위 판결문에서 언급된 ‘그 밖의 판단요소⑥’가 이에 대한 판단요소로 볼 수 있을 것이다.

두 번째의 ‘새로운 용역업체와 근로자들의 인식’을 판단요소로 내세운 것은 동일한 사용자를 대상으로 하는 기대권과 다르게 고용승계 기대권은 사용자가 변경되기 때문으로 보인다.⁵⁶⁾

한편 고용승계 기대권 법리는 아웃소싱업체의 변경 시에 적용되는 법리인데, 도급업체가 기존에 직접 처리하던 업무를 위임이나 도급의 형식으로 외부업체에게 맡겨 수행하도록 하는 외주화(outsourcing)의 경우 또는 그 역의 경우로서 도급업체가 외부업체에게 맡겨 수행하도록 했던 업무를 직접 처리하는 직영 시(insourcing)에도 동일하게 적용할 수 있는가. 생각건대 외주화의 경우는 아웃소싱업체의 변경 시와 사안의 성질이 유사하여 고용승계 기대권 법리를 적용해야 할 것으로 보이나, 직영의 경우는 오히려 도급업체가 아웃소싱업체에 맡겼던 업무를 자회사의 설립하여 자회사에 해당 업무를 위탁하면서 종전 아웃소싱업체 소속 근로자에 대해 자회사의 정규직으로 전환하여 채용하는 정규직 전환 채용 기대권의 사안과 유사하다. 도급업체가 직접 고용하거나 자회사의 설립을 통해 직접 고용하는 것은 본질적으로 다르지 않기 때문이다.

VI. 맺는 글

이상에서 1996년 대법원 전원합의체 판결 이후 기간제근로자의 고용종료를 보호하기 위해 형성된 판례 법리를 살펴보았는데, 그 핵심은 기간제근로자의 고용종료에 대해 해고제한법리를 적용한 것이다. 이와 같은 판례 법리는 유추의 방식을 통한 법형성이라 할 수 있는데, 이는 계속 고용에 대한 신뢰관계가 형성되어 있음에도 사용자에게 의해 갱신 거절 등으로 근로관계가 강제 종료되는 것은 본질적으로 ‘해고’와 같기 때문

⁵⁶⁾ 사용자가 변경되는 정규직 전환 채용 기대권의 경우에도 고용승계 기대권과 마찬가지로 ‘자회사와 근로자의 인식’을 기대권 인정의 판단요소로 내세우고 있다.

에 근로기준법 제23조 제1항과 제28조를 유추적용하는 것으로 보았다.

3개의 방향으로 형성된 판례 법리 중 구체이익과 관련된 판례 법리는 근로계약기간 중 사용자의 부당해고 등 부당한 고용종료로부터 기간제 근로자를 보호하기 위한 판례 법리이고, 사실상 무기계약 법리와 기대권 법리는 근로계약기간 만료나 용역업체의 변경 등으로 인한 고용종료로부터 기간제근로자의 근로관계를 보호하기 위한 법리라 할 수 있다. 전자의 법리는 후자의 기대권 법리와 결합하면서 계속 고용의 가능성을 넓혀왔다고 평가할 수 있다.

원직복직이 불가능하더라도 임금 상당액 등을 구할 이익이 있다는 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 판결은 근로계약기간 중의 해고 등에 대해 해고제한법리가 실질적으로 작동할 수 있도록 길을 열었다는 점에서 큰 의의가 있고, 근로기준법 제30조 제4항의 입법에 배경이 되었다. 구체이익과 관련된 판례 법리는 근로기준법 제30조 제4항의 입법으로 이제 법관의 법형성 영역에서 법발견의 영역으로 옮겨갔다고 볼 수 있다. 그런데 위 규정과 관련하여 2022년에 선고된 대법원 판례는 이와 배치되는 것으로 보인다.

사실상 무기계약 법리는 기간제근로자의 고용종료에 대한 보호장치가 없을 때 그 기능을 담당하였고, 기대권 법리의 탄생에 단초를 제공하였다는 측면에서 큰 의의가 있다. 한편 이 법리는 법원성(Rechtsquelle)을 갖지 못하는 판례가 법원(Rechtsquelle)인 근로계약의 명시적인 내용(근로계약기간)을 부인하는 해석을 하는 데에 일정한 한계가 있을 수밖에 없고, 사용기간을 제한한 기간제법의 시행으로 적용대상 영역이 축소되는 한계도 존재하는 것이 사실이다. 사실상 무기계약 법리가 담당했던 역할의 상당 부분은 이제 갱신기대권 법리가 담당하고 있고, 갱신기대권 법리는 정규직 전환 기대권, 더 나아가 고용승계기대권 등으로 외연을 확대하면서 외형적인 측면에서는 어느 정도 완결성을 갖추었다고 볼 수 있다. 그러나 개별 기대권의 판단기준이나 판단요소, 합리적 이유 등에 대한 법리는 아직 ‘형성’을 필요로 하고, 법관의 법형성이 가장 역동적으로 이루어지는 영역이 노동법 영역, 그중에서도 비정규직 근로자와 관련된 영역임을 고려하면 향후 이에 부합하는 새로운 ‘형성’으로서 판례 법

298 노동법학 제87호(2023. 9.)

리가 탄생하길 기대한다.

주제어: 법관의 법형성, 기간제근로자, 해고제한법리, 부당해고 구제신청,
구제이익, 갱신기대권 등 계속 고용 기대권

참고문헌

- 강선희, “부당해고 구제절차와 소의 이익-대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 판결”, 제2판 『노동판례백선』, 한국노동법학회, 박영사, 2021.
- 강선희, “용역업체 등의 변경 시 고용승계기대권-대법원 2021. 4. 29. 선고 2016두57045 판결-”, 월간 『노동리뷰』 2021년 7월호(통권 제196호), 한국노동연구원, 2021.
- 강선희, “용역업체 등의 변경 시 관행 등을 근거로 한 고용승계기대권 및 두 가지 의문(대법원 2021. 6. 3. 선고 2020두45308 판결)”, 월간 『노동리뷰』 2021년 9월호(통권 제198호), 한국노동연구원, 2021.
- 강선희, “위탁 등 아웃소싱과 노동법적 쟁점-기간제근로자를 중심으로-”, 『노동법포럼』 제38호, 노동법이론실무학회, 2023.
- 김영환, “법학방법론의 관점에서 본 유추와 목적론적 축소”, 『법철학연구』 제12권 제2호, 2009.
- 김영환, “한국에서의 법학방법론의 문제점 - 법발견과 법형성: 확장해석과 유추, 축소해석과 목적론적 축소 간의 관계를 중심으로 -”, 『법철학연구』 제18권 제2호, 한국법철학회, 2015.
- 박은정·권오성, “부당해고구제신청의 구제이익과 소의 이익”, 『이화여자대학교 법학논집』 제24권 제3호 통권 69호, 2020.
- 심재진, “근로관계 종료에 따른 부당해고 등 구제신청 구제이익과 재심판정취소 소송 소의 이익”, 『노동법연구』 제32호, 서울대노동법연구회, 2012.
- 유성재, “임금상당액 지급명령의 독립적 구제이익”, 『법학논문집』 제37집 제3호, 중앙대학교 법학연구원, 2013.
- 장영석, “정년 도래, 근로계약기간 만료, 폐업 등 이후 부당해고 등 구제신청과 구제이익-대법원 2022. 7. 14. 선고 2021두46285 판결-”, 월간 『노동리뷰』 2022년 9월호(통권 제210호), 한국노동연구원, 2022.
- 칼 라렌츠(김영환 역), “방법론적인 문제로서 법관의 법형성”, 『법학논총』 제25집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2008.

<Abstract>

The Case Law to protect the Fixed-term Employee
from Termination of Employment

KANG, Sun-hee^{*}

This article examined the case law formed to protect the termination of employment of fixed-term employees after the Supreme Court's All-collegial Decision in 1996, and the core of which is to apply the legal principles of dismissal restriction to the termination of employment of fixed-term employees. Art. 23 ① and Art. 28 of the Labor Standards Act is applied by analogy because termination of employment relationship due to the employer's refusal to renew, despite the trust that the employee will continue to be employed, is essentially the same as 'dismissal'. These case law is Law-Forming action(*Rechtsfortbildung*) through the method of analogy.

The case law related to the interests of remedy are intended to protect fixed-term employees from unfair termination of employment, such as unfair dismissal by the employer during the employment contract period. Legal principles on virtually non-fixed term employment contract and expectations right is the case law to protect the employment relationship of fixed-term employees from the termination of employment due to the expiration of the employment contract period or the change of outsourcing company. It can be evaluated that the former legal principle has continued to expand the possibility of employment while being combined with the latter legal principle of expectations right.

Supreme Court's All-collegial Decision 2019Du52386, decided

^{*} Lecturer, Korea Univ.

February 20, 2020 is of great significance in that it paved the way for the practical operation of the dismissal restriction legal principle for dismissal during the employment contract period, and it was the background to the legislation of Art. 30 ④ of the LSA. With this legislation, it can be seen that it has now moved from the area of law-forming action by judges to the area of law-finding. However, the recent Supreme Court precedent seems to contradict this provision.

The legal principles on virtually non-fixed term employment contract is of great significance in that it played a role in the absence of a protective device for the termination of employment of fixed-term employees, and provided the basis for the birth of expectations right. On the other hand, there is a limit to the Judge's interpretation of denying the explicit contents of the employment contract(employment contract period), which is the source of law(*Rechtsquelle*).

The right to expect renewal has been expanded to include the right to expect conversion to regular employment, and even the right to expect employment succession when changing outsourcing companies, and has achieved a certain level of completeness in terms of appearance. However, considering that the legal principles regarding the criteria for judging, judgment elements, and rational reasons, etc. for individual expectation rights still require 'Forming'. And considering that the area where judges' Law-Forming action is most dynamic is the area related to labor law, especially non-regular workers, it is expected that case law will be born as a new 'Forming' in the future.

Key Words: Law-Forming Action by Judges, Fixed-term Employee, Legal Principles of Restriction of Dismissal, Unfair Dismissal Remedy Application, Interests of Remedy, Expectations Right to Continued Employment (Renewal Expectations Right etc.)